

60회 변리사 2차 시험 특허법 해설

안녕하십니까. 정말 고생 많으셨습니다.

제59회 변리사 제2차 시험 특허법 답안을 업로드합니다. 올해 특이점으로는 ① 5~6년 주기에 속하던 PCT 문제가 출제되지 않은 점, ② 정정심결 재심사유 관련 전합판례가 선고된 후 3년 동안 출제되지 않은 점, ③ 문제 1 및 문제 4에서 다소 배점이 낮은 문제들이 많이 출제된 점, ④ 최근 58회, 59회 경향과 달리, 비교적 최신 판례들의 사실관계를 기반으로 하여 최신 판례를 큰 배점 하에 통으로 쓸 수 있는 문제들이 거의 출제되지 않은 점, ⑤ 과거 57회 이전과 같이, 최신 판례들보다는 전통적인 판례들에 대한 문제 또는 절차조치 문제들이 다소 많이 출제된 점, ⑥ 다소 오래된 판례지만 간접침해에 대한 리딩케이스 판례로서 반도체 웨이퍼 연마패드 사건의 사실관계가 거의 그대로 출제된 점, ⑦ 특유발명인 선택발명 문제와 특유 청구항인 PbP 청구항 문제가 출제되었지만 배점이 다소 낮게 출제된 점 등에 있습니다.

올해 특허법 시험 문제의 난이도를 평가하면, ① 동차생들도 다소 평이하다고 느낄 수 있는 요인으로서, 외국 판례나 최근 트렌드의 특유한 문제보다는 “전통적인 논점들과 수험가 A급 논점들이 주로 출제”된 점, ② 기득 이상들도 다소 어렵다고 느낄 수 있는 요인으로서, “출제의도나 사실관계가 다소 애매한 조치 문제들이 다소 출제”되었고 “시험장 압박 및 긴장 속에서 시간 및 배점을 고려하여 애매한 문제들에 대한 순간적인 답안 작성에 어려움”이 있을 수 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 현장 체감 난이도는 “중~중상”으로 판단됩니다.

모두 고생 많으셨습니다. 각자 노력하신 만큼 좋은 결과를 얻으시길 바랍니다.

변리사 수험생들 전체의 평균적인 현장 체감 난이도 예측	중~중상
--------------------------------	------

(주) 한빛지적소유권센터
특허법 강사 일동 배상

문제 1

(1) 특허법상 권리범위확인심판제도의 취지를 고려하여 권리범위확인심판제도와 특허권 침해소송과의 차이점을 설명하시오. (2점)

I. 설문(1)

1. 권리범위확인심판제도의 취지

객관적인 속부판단 -> 간이·신속한 분쟁의 예방 및 종결

2. 특허권 침해소송과의 차이점 - 判例

권리범위확인심판은 ① 침해소송과 같이 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니지만, ② 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다. (2016후328)

* 구체적인 차이점 : 심리범위, 집행력 등 +@ 가능 (다만, 배점 한계 존재)

(2) 다음과 같은 이유로 청구된 권리범위확인심판의 타당성에 관하여 설명하시오. (12점)¹⁾

1) 乙의 발명 X'에 관련된 물건과의 관계에서 甲의 특허권이 소진되었음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우

2) 甲의 특허발명 X에 진보성이 없음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우

3) 乙의 발명 X'가 甲의 특허발명의 X의 구성요소 중 일부를 변경하였음을 이유로 甲이 권리범위확인심판을 청구하는 경우

4) 乙이 장래 실시할 수도 있음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우

II. 설문(2)-1)

1. 권리범위확인심판에서 소진이론 심리판단 가부 : 불가 - 判例 (2010후289)

2. 사안

소진이론 심리판단 불가 -> 부당

III. 설문(2)-2)

1. 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성 심리판단 가부 : 불가 - 전합 判例 다수의견 (2012후4162)

2. 사안

특허발명의 진보성 심리판단 불가 -> 부당

* 선결문제, 권리남용 관련 내용 등 +@ 가능 (다만, 배점 한계 존재)

IV. 설문(2)-3)

1. 균등론 - 判例

~~ 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다고 한다. (2017후424)

2. 사안

균등론 심리판단 가능 -> 일응 타당

* 다만, 구성 일부를 변경하였다는 사정“만”으로 권리범위에 속한다고 주장하는 것은 부당

V. 설문(2)-4)

1. 소극적 권리범위확인심판 청구인 적격 : 이해관계인 - 法 제135조 제2항

2. 이해관계인 : 현재 실시자 + 장래 실시 예정자 - 判例 (97후3241)

3. 확인대상발명 적격 : 현재 실시하는 것 + 장래 실시 예정인 것 - 判例 (2014후2849)

4. 사안

장래 실시 예정 소극적 권리범위확인심판 -> 타당

1) 참고 - 문제의 러프함

“심리범위 내지 심판 적부 및 본인”을 모두 포괄하여 “심판의 타당성”이라는 표현으로 물어본 것으로 판단됨.

(3) 甲의 발명 X의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명인 경우에 乙의 발명 X'의 실시가 甲의 권리범위에 포함되는지 여부를 판단할 때 확인대상 발명 X와 대비해야 할 사항을 설명하시오. (4점)

VI. 설문(3)

1. PbP 청구항 여부 - 적극

2. 침해요건 판단 시 청구범위 해석방법 - 判例 (2013후1726, 2020후11059)

3. 사안

원칙 : 해당 제조방법을 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 구조나 성질 등을 갖는 물건을 대비.

예외 : 명백히 불합리한 사정이 있는 경우 -> 제조방법 자체를 대비 가능.

(4) 甲은 2023. 5. 10. 법원에 특허권 침해소송을 제기하였고, 이에 乙은 권리범위확인심판 대신에 특허무효심판을 청구하였다. 특허무효심판의 심결과 관련하여 甲이 취할 수 있는 조치에 대하여 설명하시오. (12점)

VII. 설문(4)

1. 무효심판 관련 조치

(1) 심결 전 조치

1) 신속심판청구 (+@)

2) 무효사유가 부존재한다고 판단되는 경우 - 무효사유 다툼

3) 무효사유가 존재한다고 판단되는 경우 - 정정청구 (法 제133조의2)

(2) 인용심결 선고 후 - 심결취소소송 (法 제186조)

(3) 심결취소소송 계속 중 조치

1) 무효사유가 부존재한다고 판단되는 경우 - 무효사유 다툼

2) 무효사유가 존재한다고 판단되는 경우 - 정정심판 청구 (法 제136조)

* 정정심판 청구 시, 독점적 통상실시권자 동의 필요 (法 제136조 제8항)

2. 침해소송 관련 조치

(1) 소송중지신청 - 法 제164조 제2항

(2) 권리남용의 항변 관련

1) 무효사유가 부존재한다고 판단되는 경우 - 무효사유 다툼2)

2) 무효사유가 존재한다고 판단되는 경우 - 정정의 재항변 (判例)

* 정정의 재항변 시, 독점적 통상실시권자 동의 필요 (法 제136조 제8항 참조)

3. 독점적 통상실시권자 관련 조치 (+@)

(1) 무효심결 확정 시 기지급 실시료 반환청구 - 불가 (判例)

(2) 무효심결 확정 시 미지급 실시료 지급청구 - 가능 (判例)

4. 기타 조치 - 화해, 조정, 중재 등

2) 참고 - 권리범위 부정 또는 권리남용 관련

침해소송에서 무효사유가 주장된 경우 이를 “부인”할 수 있음.

문제 2

(1) 甲은 2022. 2. 10. 발명 A에 대하여 학위논문을 작성하여 발표하였는데, 발명 A에 대하여 특허출원 X를 할 때 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)에 의한 공지에외주장을 하지는 않았다. 심사관은 공개된 甲의 논문에 의해 신규성 상실을 이유로 甲의 특허출원 X에 대하여 거절이유를 통지하였고, 甲은 특허출원 X의 보정기간 내에 보정을 하거나 분할출원을 통해 특허법 제30조에 의한 공지에외주장을 하여 거절이유를 극복하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (9점)

I. 설문(1)

1. 공지에외주장

- (1) 의의, 취지 - 法 제30조
- (2) 요건, 효과 - 法 제30조 제1항
- (3) 사안 - 요건 모두 충족, but 의사에 의한 공지 -> 절차 문제

2. 보정기간 내 공지에외주장 당부

- (1) 공지에외주장 절차 - 法 제30조 제2항
- (2) 공지에외보완 - 法 제30조 제3항
- (3) 사안 - 타당 (경과규정상 개정법 적용, 法 제30조 제3항 제1호)

3. 분할출원 시 공지에외주장 당부

- (1) 분할출원 의의, 취지 - 法 제52조
- (2) 종속성 관련 判例 (이는 특허법 제30조 제3항의 신설 전후를 불문하고 일관되게 해석)
- (3) 사안 - 타당

* 기타 분할출원 관련 일반론 +@ 가능 (다만, 배점 한계 존재)

(2) 심사관은 출원단계에서 선행발명 Y에 의거하여 甲의 특허출원 X가 진보성이 없다는 이유로 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였지만 특허심판원은 기각심결을 하였다. 이에 甲은 심결취소소송을 제기하였고, 심결취소소송단계에서 특허청은 甲의 특허출원 X가 선행발명 Z에 의거하여 진보성이 없다고 주장하였다. 특허청의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (6점)

II. 설문(2)

- 1. 심결취소소송 심리범위 - 判例 (+@)
- 2. 거절결절불복심판 심결취소소송의 경우 - 判例
- 3. 주선행발명을 변경한 경우 - 判例 (2015후2341) (+@)
[또는 제시하는 인용문헌이 다른 경우 - 判例 (98후515)]
- 4. 사안 - 선행발명 변경 -> 특별한 사정이 없는 한, 새로운 거절이유 -> 부당

* 심결취소소송 관련 일반론, 관련 학설, 검토 등 +@ 가능 (다만, 배점 한계 존재)

(3) 甲은 2022. 10. 20. 乙에게 발명 A에 대한 특허출원 X 및 그에 관한 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였는데, 乙은 특허출원인변경신고를 하지 않았다. 甲은 특허출원 X를 원출원으로 하여 분할출원을 하였고, 심사에 불복하는 심판을 청구하였으나 기각심결되었고, 특허심판원으로부터 심결등본을 송달받았다. 甲으로부터 심결등본을 전달받은 乙이 심결취소소송을 제기하려고 한다. 乙이 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자로서 적합한지에 관하여 설명하시오. (5점)

III. 설문(3)

- 1. 심결취소소송 원고 적격 : 당.참.거 - 法 제186조 제2항
- 2. 출원 후 승계의 효력발생요건 - 특허법 제38조 제4항
- 3. 관련 判例 - 특허출원인변경신고 없이 심결취소소송 제기불가 (2015후321)
- 4. 사안 - 부적합

문제 3

(1) 甲은 乙과 丙을 상대로 특허권 침해 주장을 하려고 한다. 甲의 특허권 침해 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (12점)

I. 설문(1)

1. 乙 상대 침해 주장 당부

(1) 전제 (+@)

독자적으로 발명을 완성하였다는 사정"만"으로 침해 성립이 부정되는 것은 아님.

(2) 특허발명 확정 - A+B+C (+@)

(3) 실시제품 확정 - A+C+M (+@)

(4) 직접침해 여부 - 소극

(5) 간접침해 여부

1) 간접침해 의의, 취지 - 法 제127조

2) 물건발명의 경우 - 法 제127조 제1호

3) 물건 생산의 의미 - 判例 (2007후3356)

4) 타용도 판단방법 - 判例 (2007후3356)

5) 사안 - 간접침해 성립

(6) 소결 - 침해 주장 타당

* ① 확인대상발명(A+M+C)을 특허발명(A+B+C)과 대비하면, 대형유동채널(A) 및 균일한 고체 중합체 시트(C)와 동일한 구성을 가지면서 소형유동채널(B)이 결여되어 있고 마이크로 홀(M)이 부가되어 있다는 점에서 차이가 있으나, ② 확인대상발명의 물건을 공급받은 사람(제3자)이 연마패드를 사용하여 화학적 기계적 평탄화 공정을 수행하면 브레이크 인 및 컨디셔닝 공정이 필수적으로 부가되고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 확인대상발명의 연마패드(A+M+C)에는 특허의 소형유동채널(B)과 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈(b)이 반드시 형성되므로(A+M+b+C), ③ 확인대상발명의 물건은 특허 물건의 생산에만 사용되는 것이어서 원고가 업으로서 확인대상발명의 물건을 생산·판매한 행위는 권리범위확인심판의 심결시를 기준으로 하여 특허권에 대한 간접침해에 해당된다. ④ 확인대상발명이 마이크로 홀(M)이라는 기술수단에 의하여 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있어 진보된 발명일 수 있다는 점 등은 그러한 결론에 영향이 없다. (2007후3356 참조)

2. 丙 상대 침해 주장 당부

(1) 특허발명 확정 - A+B+C (+@)

(2) 실시제품 확정 - A+b+C+M [b = 줄무늬 홈] (+@)

(3) 이용침해 법리 - 判例

(4) 사안 - 직접침해 성립

(5) 결론 - 침해 주장 타당

* 丙은 乙로부터 공급받은 A+C+M에 대해 컨디셔닝(conditioning) 공정 등을 수행하여 A+b+C+M을 업으로서 가공(생산)하였음. 실시제품의 줄무늬 홈(b)는 소형유동채널(B)과 동일한 구조와 기능을 수행하므로, 줄무늬 홈(b)는 소형유동채널(B)과 동일(내지 균등)한 구성이며, 마이크로 홀(M)이라는 기술수단에 의하여 甲의 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있더라도 (이용)침해 성립 가능.

* (+@) 丙은 고의침해에 해당함 (물론 징벌적 손해배상, 침해죄 등이 가능하겠지만, 설문(1)은 조치문제가 아니므로 특별한 실익 X)

3. 결론 - 모두 타당

* 甲은 사용방법에 대한 특허도 보유하고 있어 논리적으로는 이에 대해 침해 여부를 검토해줄 수 있지만, 이는 2007후3356 판결의 사실관계와 동일하게 제시한 것일 뿐 특별히 실익이 없는 것으로 판단하였음.

(2) 丁은 甲의 연마용 패드의 반제품을 생산하고 있으며, 丁이 생산한 반제품은 조립하여 완제품으로 제작될 수 있다. 丁은 甲의 연마용 패드 반제품을 생산하여 제3국에 수출하였고, 戊는 제3국에서 이 반제품을 이용하여 완제품을 생산하고 있다. 甲은 丁과 戊를 상대로 특허권 침해를 주장하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (8점)

II. 설문(2)

1. 戊 상대 침해 주장 당부

(1) 속지주의 원칙 - 判例

(2) 사안 - 침해 부정

(3) 소결 - 침해 주장 부당

* 제3국 완제품 생산(특허물건 생산)에 대해 특허권 효력을 주장할 수 없음.

2. 丁 상대 침해 주장 당부

(1) 반제품 수출 관련 - 判例

1) 직접침해 관련 - 判例

2) 간접침해 관련 - 判例

(2) 사안 - 조건부 직접침해 성립 가능

(3) 결론 - 조건부 침해 주장 타당

* 만약, 丁이 생산한 반제품이 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 것이고, 마지막 단계의 조립이 극히 사소하거나 간단 -> 직접침해 성립 가능.

* 그렇지 않다면 -> 직접침해 부정, 간접침해 부정.

3. 결론 - 戊 상대 침해 주장 부당 / 丁 상대 침해 주장 조건부 타당

(3) 특허권자 甲은 자신의 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조·판매할 수 있도록 X와 통상실시권을 허락하는 계약을 체결하였다. 그 후 통상실시권자 X는 甲의 특허발명 중에서 반도체 웨이퍼 연마용 패드의 전용품인 대형유동채널(A)을 제작 및 납품하는 계약을 Y와 체결하였고, Y는 대형유동채널(A)을 제작하여 X에게 납품하고 있다. 甲이 Y에 대하여 특허법상 취할 수 있는 조치에 관하여 설명하시오. (10점)

III. 설문(3)

1. 직접침해 여부 - 부정

2. 간접침해 여부

(1) 직접침해 전제 여부 (+@)

(2) 실시권자 공급 관련 - 判例 (2017다290095)

(3) 사안

* Y가 통상실시권자에게 전용품을 공급하면, 위 判例의 태도에 따라 간접침해 부정.

* 다만, X는 특허발명(A+B+C)의 실시 자체를 허락받은 자가 아닌, "특허발명(A+B+C)을 실시하는 데 적합한 장비(예: 특허발명(A+B+C)의 전용 제조장치)의 제조·판매"만을 허락받은 자이므로, Y로부터 납품받은 전용품인 대형유동채널(A)을 통해 특허발명(A+B+C)을 실시하면 직접침해가 성립할 수 있어, 간접침해 성립 여지 존재.³⁾

3. 결론

* 간접침해가 부정되는 경우, 甲은 Y에 대해 아무런 조치 불가.

* 다만, 甲은 적극적으로 Y의 간접침해를 주장·입증하여 특허권 행사를 "시도"해 볼 수 있음 (구체적으로, 甲은 Y에 대해 권리범위확인심판 및 민사적 조치를 "고려"해 볼 수 있음. 다만, 형사적 조치는 취할 수 없음).

3) 직접침해 관련 문제

2017다290095 사건은 특허발명 자체에 대한 통상실시권자에게 전용품을 공급하였고 통상실시권자가 전용품을 통해 특허발명을 실시하였으므로 통상실시권자에게 직접침해가 성립되지 않았던 사건인데, 본 문제에서는 계약 해석에 따라 X에게 직접침해가 성립될 여지가 존재하므로, 甲은 Y에게 간접침해를 적극적으로 주장, 입증하여 특허권을 행사하는 것이 바람직하다고 판단됨.

문제 4

(1) 선택발명에 대해 설명하고, 乙의 선택발명이 진보성을 인정받기 위한 요건에 관하여 설명하시오. (5점)

I. 설문(1)

1. 선택발명

2. 乙의 선택발명이 진보성이 인정받기 위한 요건

(1) 진보성 의의, 취지 - 法 제29조 제2항 (+@)

(2) 선택발명 관련 判例 (2001후2740, 2005후3338, 2008후736, 2010후3424 등⁴⁾ 및/또는 2019후10609, 2020후11738)

(3) 사안

하위개념 개수 2개 -> 특별한 사정이 없다면 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안
-> (역교시 또는) 효과의 현저성 필요⁵⁾

(2) 다음의 경우에 甲과 乙의 출원 중에서 후출원을 실시하는 것이 선출원의 특허권을 침해하는지 여부에 대하여 설명하시오. (단, 후출원은 등록되지 않은 것으로 가정한다.) (5점)

- 1) 甲의 특허출원이 선출원인 경우
- 2) 乙의 특허출원이 선출원인 경우
- 3) 甲과 乙의 출원이 동일자 출원인 경우

II. 설문(2)-1)

1. 선택침해 관련 - 判例 (90후960)

2. 사안

if 효과가 양적으로 현저 X -> 침해 O⁶⁾

if 효과가 양적으로 현저 O -> 침해 X

* 판례의 태도에 따른 결론을 기재한 것임 (if 효과 현저 → 다른 발명 → 침해 X).

* 절충설에 따르면 모두 침해 성립 (모두 심혈관 치료물질 -> 동질 효과).

III. 설문(2)-2)

if A+B+C₁ 실시 -> 문언침해 X, 균등침해 △

if A+B+C₂ 실시 -> 문언침해 O

IV. 설문(2)-3)⁷⁾

침해 X

4) 참고 - 종래 판례 선택해석

종래 判例들(2001후2740, 2005후3338, 2008후736, 2010후3424 등)은 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지임 (2019후10609 참조)

5) 참고 - 구성의 곤란성 기준

효과는 구성의 곤란성 판단 시 1 고려요소에 해당함. 효과가 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료임.

6) 참고 - 선택침해 논의 관련

효과가 현저하지 않은 경우 하위개념이라도 침해가 성립된다는 점에 있어서 이견 無.

7) 참고 - 애매한 문제

엄밀히는 문제 오류지만, 동일자 출원경합 시 상호 자신의 발명을 자유실시할 수 있다는 것이 출제의도인 것으로 판단하였음.

(3) 실험관 치료물질에 관한 발명 X에 대하여 특허를 받은 甲은 특허발명 X의 구성요소 중 C가 丙의 발명의 구성요소 M과 과제해결원리가 동일하다고 판단하고 있다. 이에 甲은 丙을 상대로 특허권 침해를 주장하려고 한다. 丙은 甲의 특허권 침해 주장이 부당하고 판단하고 있다. 丙이 甲의 특허권 침해 주장에 대하여 취할 수 있는 대응조치에 대하여 설명하시오. (10점)

Ⅲ. 설문(3)

1. 침해 부정 주장

(1) 문언침해 부정 주장 (+@)

(2) 균등침해 부정 주장

1) 균등론 의의, 취지, 근거

2) 요건 - 判例

3) 과제해결원리 동일성 관련 - 判例

4) 작용효과 실질적 동일성 관련 - 判例

5) 사안

① 출원 전 공지기술 조사

ㄱ. 과제해결원리의 동일성 관련

특허발명의 기술사상의 핵심에 관한 출원 전의 공지기술을 찾아,
과제해결원리의 동일성의 폭을 좁혀 과제해결원리 동일성에 대해 다툼 시도

ㄴ. 작용효과의 실질적 동일성 관련

특허발명의 기술사상의 핵심에 관한 출원 전의 공지기술을 찾아,
특허발명의 기술사상의 핵심이 공지되었음을 이유로
구성 개별적인 관점에서 작용효과 실질적 동일성에 대해 다툼 시도

ㄷ. 자유기술 관련

실시발명에 관한 출원 전 공지기술을 찾아, 자유기술임을 주장, 입증 시도

② 출원경과 조사

출원경과 참작을 통해, 실시발명의 구성이 의식적 제외되었음을 주장, 입증 시도

③ 그 밖에 대응조치

통상의 기술자라면 누구나 쉽게 변경할 정도인지에 대해 다툼 시도

* 한편, 발명전체맥락에서 과제해결원리의 동일성을 판단해야 한다고 주장하면 오히려 불리해질 수도 있음.

2. 기타 조치 (+@)⁸⁾

(1) 무효사유 조사

신규성, 진보성, 기재불비 등을 통해 권리남용의 항변 등을 시도

(2) 행정심판 등 이용

무효심판, 소극적 권리범위확인심판 등 이용 가능

(3) 기타

실시허락, 특허양수, 화해·조정·중재 등 고려 가능

8) 참고 - 출제의도 분석

설문 전체의 취지상 “균등침해 주장에 대한 대응조치”가 주논점으로 파악됨.